

1501215-72.2020.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE EDUARDO CANDIDO DE MEIRA JUNIOR

Data da Audiência:

30/11/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501215-72.2020.8.26.0571 - Controle 2020/001614

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE EDUARDO CANDIDO DE MEIRA JUNIOR

Data da Audiência:

30/11/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado José Eduardo Candido de Meira Júnior. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foi ouvida a testemunha Thiago Coutinho Moraes arrolada pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Renato Antonio Cardena, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos em juízo,

os policiais responsáveis pela prisão do réu narraram, em tom uníssono, que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado e outra pessoa em atitudes suspeitas, sendo certo que ao se aproximarem notaram que o agente colocou algo no bolso. Na abordagem e revista, constataram que se tratava dos cigarros de maconha, sendo certo que com a outra pessoa que o acompanhava, identificada como Sabrina, foi localizado e apreendido um cigarro de maconha que havia adquirido do acusado para seu próprio consumo, pelo valor de R\$ 10,00. Ainda mencionaram que depois da abordagem o acusado admitiu que possuía mais drogas em sua casa, pelo que se dirigiram até o local, e tendo sido franqueado o ingresso na casa, localizaram cigarros consumidos e outras três porções do entorpecente. As palavras dos policiais revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição dos policiais; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. Demais disso, em solo policial, o acusado confessou a prática do tráfico, inclusive a venda do cigarro à pessoa da Sabrina. Essa confissão extrajudicial está a merecer crédito, haja vista que corroborada por elementos de prova colhidos sob o pálio do contraditório. E a retratação em juízo restou isolada, além do que não foi capaz o acusado de dar uma justificativa minimamente idônea das razões pelas quais teria confessado a autoria do tráfico. Dessa forma, é patente a responsabilidade penal do acusado pelo delito tipificado no artigo 33 da lei de prevenção e repressão às drogas, haja vista as circunstâncias em que se deu a prisão, evidenciando que os entorpecentes eram destinados à ulterior entrega ao consumo de terceiros, tanto que havia acabado de vender um cigarro de maconha para a pessoa que ali se encontrava. Aliás, por outro lado, não há como se aceitar que eventual condição de usuário sugeria venha a elidir o tráfico, até porque bastante comum nos dias atuais o comércio ilícito de drogas até para sustento do vício. Demonstradas, pois, autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. Senão vejamos. I – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade de entorpecentes e como o réu foi preso apenas – de acordo com o depoimento do policial – na posse de pequena quantidade de entorpecente e consumindo junto com sua prima Sabrina, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. Aliás, é de se destacar que, em que pese a versão policial no sentido de que Sabrina teria confirmado que comprou entorpecente do acusado, fato é que a testemunha não foi ouvida em juízo para esclarecer a dinâmica dos fatos. O policial ouvido declarou que, em posse do réu, foi localizada pequena quantidade de maconha e que, em sua residência, havia cigarro de maconha já consumido, tudo indicando se tratar dele de mero usuário. O próprio réu esclareceu que se trata de usuário e que o entorpecente apreendido era para seu uso. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presuma que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de as substâncias estarem embaladas individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que o réu declarou que possuía os entorpecentes para seu consumo pessoal. De fato, o caso envolve diminuta quantidade de entorpecente, indicando se tratar de hipótese de uso. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro

(circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. II- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 33, § 3º, DA LEI Nº 11.343/06 – Caso não haja a desclassificação anteriormente pretendida, requer a defesa, ainda, seja a conduta ajustada ao tipo penal previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06, como se passa a expor na sequência. Isto porque, ainda que se considere (em que pese não haja elementos probatórios para tanto, como já frisado) que ele ofereceu maconha para Sabrina no local em que as diligências ocorreram, não há como se sustentar uma condenação com fulcro no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ora, conforme já visto, a acusação não logrou êxito em demonstrar o intuito lucrativo do denunciado, já que as provas para tal mister restaram amparadas apenas nos relatos dos próprios investigadores. Ademais, conforme consta nos autos, Sabrina era prima do réu e, portanto, é crível que estivessem consumindo drogas em conjunto. Logo, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, a conduta que poderia lhe ser imputada, no máximo, é a de que ofereceu a droga, sem intuito lucrativo, para que a prima a consumisse junto consigo. Logo, está configurada, quando muito, a conduta descrita no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS – Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer: i) fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, considerando QUE O ACUSADO É PRIMÁRIO, sendo que a sua culpabilidade não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal; ii) na segunda fase de dosimetria, requer seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, caso ela seja valorada pela sentença, iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, no seu patamar máximo, eis que o acusado não se dedica à atividade criminosa, nem integra organização criminosa, estando, pois, presentes todos os requisitos legais para o gozo de tal benefício. (iv) seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e da súmula nº 440 do E. STJ, observando-se, ainda, o disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (v) haja a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão da Resolução do Senado nº 5 de 2012 e das inúmeras decisões do Supremo (Plenário e Turmas), reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.434/06, que continha tal vedação (v.g. STF – Segunda Turma – HC nº 110.920/MG – rel. Min. Carmen Lúcia – j. 19/02/2013); (vi) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. JOSÉ EDUARDO CÂNDIDO DE MEIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de setembro de 2020, por volta das 21 h e 08 min, na Rua Maria José Rocha Thibes, n. 97, Vila Rocha, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sete porções de “maconha”, com peso de 12,85 gramas, e seis cigarros de “maconha”, com peso de 1,97 gramas. Notificado, fls. 102, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 106/107. A denúncia foi recebida, fls. 108/109 e o Réu, citado, fls. 127. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a desclassificação. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 10/12, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 13/14, no Laudo de Constatação, fls. 29/30, bem como no Exame químico-toxicológico n. 290.519/2020, fls. 52/55, contatando-se a presença do princípio ativo TETRAHIDROCANABINOL (THC). Thiago Coutinho Moraes, policial militar, testemunha, disse que estavam em

patrulhamento quando se depararam com o Réu e Sabrina, tendo o Acusado, ao ver os policiais, guardado alguma coisa no seu bolso; os policiais fizeram a abordagem, instante em que Sabrina entregou um cigarro de maconha que havia acabado de adquirir do Réu por R\$ 10,00. Com o Acusado houve a localização de 04 porções de "maconha" e de R\$ 24,00 e um aparelho de celular; o Réu disse que na casa existiam outros entorpecentes, para onde rumaram e lá apreenderam o restante das drogas. José Eduardo Cândido de Meira Júnior, Réu, ao ser interrogado, disse que as drogas eram suas, porém para uso. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, os policiais estavam em serviço quando viram o Réu e Sabrina, os quais estavam sentados na calçada; ao ver os policiais o Acusado guardou em seu bolso algo, o que levou os policiais a realizarem a abordagem; nesse momento Sabrina entregou um cigarro de "maconha" que havia acabado de comprar do Réu por R\$ 10,00, e, com o Acusado, os policiais apreenderam 04 porções de "maconha", e, na sua casa, havia seis cigarros de "maconha" e três porções de "maconha". As drogas, pela quantidade e pela forma de partilha destinavam-se ao comércio ilícito. Ademais, havia dinheiro, fruto de vendas pretéritas, o que se infere da ausência de demonstração de trabalho lícito e de todas as demais circunstâncias já apontadas nesta sentença. Por fim, o Réu confessou a prática do crime na fase policial, apesar de, em Juízo, negar o comércio ilícito, tese que não pode ser acolhida ante as circunstâncias. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, guardar e manter em depósito, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: O Réu confessou o delito, logo faz jus a atenuante da letra "d", do inc. III, do art. 65, do Código Penal, com redução de 1/6. Todavia, na segunda etapa, a atenuante da confissão não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz

sentenciante, numa “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar JOSÉ EDUARDO CÂNDIDO DE MEIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias – multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Decreto a perda dos bens e dos valores apreendidos. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 30 de novembro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA